

1501298-79.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBSON BARBOSA LIMA

Comarca: Guararema

Foro: Foro de Guararema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... se pode esquecer que o delito de tráfico pode ser classificado como crime de "ação múltipla", já que diversos "verbos" o configuram. Logo, ainda que se verifique a indução da alienação, não há como afastar a aquisição e depósito para fins de tráfico. Não se consubstancia o delito de tráfico o ato de vender, mas englobando outras condutas que se amoldam perfeitamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararema

Foro de Guararema

Vara Única

Rua Expedicionário Brasílio Pinto de Almeida, 42, . - Centro

CEP: 08900-000 - Guararema - SP

Telefone: 11-2838-7660 - E-mail: guararema@tjsp.jus.br

1501298-79.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501298-79.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CRISTHIAN DA SILVA MORAES OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBSON BARBOSA LIMA

Vistos.

Cristhian da Silva Moraes Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque em 01 de junho de 2022, neste Município, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, entorpecentes consistentes em 65 (sessenta e cinco) invólucros plásticos contendo crack e 90 (noventa) contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

À fl. 74 foi determinada a notificação do réu a respeito dos termos da denúncia.

Devidamente notificado, o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 77/83;

contudo, não trouxe elementos aptos a impedir a admissibilidade da peça acusatória, razão pela qual ela foi recebida às fls. 103/104.

Por ocasião das audiências de instrução, foram ouvidas cinco testemunhas e interrogado o réu (fls. 158/164).

Em alegações finais, a acusação pugnou pela procedência da ação penal condenando-se o réu nos exatos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu nulidade por vício na abordagem e absolução no mérito, subsidiariamente, requereu pena abaixo do mínimo, regime aberto e direito de recorrer em liberdade.

Eis o relato do necessário.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa é indubitosa diante do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e laudo de exame químico-toxicológico.

No tocante à autoria, carece perquirir acerca da prova produzida.

Pois bem, pode-se falar em indícios da ocorrência, pela documentação existente nos autos, do delito narrado na peça acusatória. Não me descuro que os indícios, entendidos como circunstâncias conhecidas e provadas, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir se a existência de outra, ou outras circunstâncias (art. 239, CPP), bem como a presunção, donde se deduz o desconhecido do conhecido, partindo-se do princípio da identidade, são entendidos como prova indireta (indícios e presunções), tal como ensina Nicola Framarino Dei Malatesta, em sua A lógica das Provas em Matéria Criminal, provenientes do raciocínio indutivo, sendo certo que indícios e presunções são e devem ser considerados como provas, pois:

Se o homem só pudesse conhecer pela própria percepção direta, bem pobre seria o campo dos seus conhecimentos: pobre no mundo das idéias, pobre no dos fatos. Para que um fato seja percebido diretamente, torna-se necessária a coincidência de lugar e tempo entre eles e o homem que o deve perceber (...) o homem é simplesmente um ponto na amplidão infinita do espaço, não mais que um átomo fugitivo no infinito desenvolvimento do tempo (...) a grande quantidade de acontecimentos está fora da esfera das nossas observações diretas e são, por isso, bem poucos os fatos que podemos conhecer por visão direta (obra e autor citados, página 187).

Contudo, os indícios não podem ser acoimados de eiva dubitativa, distanciando-se, pois, do conceito de suficiência.

Assim sendo, socorre-se não só da prova documental e dos indícios, como também, principalmente, da prova oral.

Em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a ela e em depoimentos prestados por terceiros, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas e testemunhas, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.

Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito.

Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima e as testemunhas, como o é se praticado contra a pessoa do acusado.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO Tráfico de Drogas - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos, caracterizando o delito de tráfico de drogas ante a diversidade, quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, bem como, pela prova documental e oral. Negativa judicial restou divorciada, frente aos depoimentos dos policiais firmes e seguros, considerados como base probatória da condenação. Pena e regime prisional corretamente fixados. Recurso Improvido”. (Apelação nº 990090134593, Rel. Edison Brandão, 16ª Câ. Dir. Criminal, TJ/SP, 20.10.09).

“Tráfico de entorpecentes- Autoria e materialidade comprovadas. Quantidade de droga

e forma de condicionamento que demonstram a traficância. Depoimentos de policiais, contra os quais nada de concreto se alegou. Desclassificação para uso afastada. Condenação bem proferida. Dosimetria correta. Recurso improvido". (Apelação nº 990080755072, Rel. Galvão Bruno, 9ª Câ. Dir. Criminal, TJ/SP, 15.10.09).

Os relatos das testemunhas são claros e trazem à baila a dinâmica dos fatos, não havendo distorções nos depoimentos; o que torna perfeitamente crível a hipótese de o acusado ter cometido o delito narrado na peça acusatória.

As testemunhas confirmaram a versão apresentada na fase policial.

Vê-se que há declarações precisas e seguras das testemunhas de acusação, em todas as oportunidades em que elas foram ouvidas, atestando a ocorrência do delito contra a saúde pública. Portanto, não obstante os diversos argumentos apresentados pela Defesa, o Juízo não possui motivos para duvidar das testemunhas e dos demais elementos de convicção contrários ao acusado, restando comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico.

Anoto que as pessoas ouvidas apresentaram um discurso coerente e um comportamento condizente com a gravidade da situação relatada. Por outro lado, analisando todos os depoimentos, vê-se que inexistem motivos para se desconfiar que as testemunhas pudessem estar inventando uma história tão séria e apenas para prejudicar a pessoa do acusado.

Saliente-se que, o fato de testemunhas serem policiais em nada enfraquece os seus depoimentos; ao contrário, pois, no seu mister, têm a obrigação de zelar pela esmerada aplicação da lei penal, não se tornando impedidas ou suspeitas (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia: As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

Comprovou-se que o acusado estava na posse das drogas. Os milicianos viram o momento em que o réu tentou dispensar o entorpecente.

Nada, absolutamente nada, nos autos leva a crer que há probabilidade de os fatos terem ocorrido na forma descrita pelo acusado.

Com todo o respeito, a tese da defesa não encontra amparo na instrução probatória, vez que suscita uma dinâmica dotada de alto grau de criatividade.

Deve-se ter em mente que os policiais abordaram outras pessoas. Assim, por lógica, não há sentido em dizer que os policiais incriminariam, falsamente, somente o acusado, deixando os demais abordados livres. Não há justificativa ou lógica para o pensamento da defesa.

As testemunhas que atenderam a ocorrência, relataram que estavam verificando uma notícia de tráfico.

O réu coincidia com as características mencionadas.

Ainda, importante mencionar que a droga foi localizada em local não habitado. Neste ponto, mesmo que se admitisse a versão do acusado, de que os policiais adentraram a sua residência, verifica-se que, mesmo assim, melhor sorte não teria o réu.

O réu e suas próprias testemunhas foram claras ao dizer que foi autorizada a entrada. O réu disse claramente que permitiu a entrada.

Ora, se o acusado permitiu a entrada em sua residência, não há motivos para se suspeitar da legitimidade da abordagem e localização da droga.

Fique claro. Independentemente da versão, houve correta abordagem e localização da substância ilícita.

Não se pode esquecer que o delito de tráfico pode ser classificado como crime de "ação múltipla", já que diversos "verbos" o configuram. Logo, ainda que se

verifique a indução da alienação, não há como afastar a aquisição e depósito para fins de tráfico. Não se consubstancia o delito de tráfico o ato de vender, mas englobando outras condutas que se amoldam perfeitamente ao delito do artigo 33 da Lei de Drogas.

Neste sentido já decidiu a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“CRIME IMPOSSÍVEL Tóxicos Tráfico Flagrante preparado Reconhecimento

Impossibilidade O tipo penal que define o delito tem vários núcleos e, embora o ato de vender cocaína tenha sido provocado por um policial, é inegável que as condutas anteriores de “manter em depósito” e “trazer consigo”, já estavam consumadas. À evidência, não há induzimento ou provocação do delito por parte dos agentes policiais quando o delito é preexistente à atuação dos mesmos. Precedentes jurisprudenciais que se amoldam exatamente à espécie. Ademais, o crime de tráfico de entorpecente é de natureza permanente e a venda fictícia é apenas mais um elemento a demonstrar a finalidade do depósito do entorpecente, ao lado de outros, tais como a sua quantidade e acondicionamento. Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. 998.213-3/7 São Paulo 14ª Câmara do 7º Grupo da Seção Criminal Relator: Alfredo Fanucchi 15.03.07 V.U. Voto n. 4.643)

A forma como a droga foi encontrada, a circunstância dos fatos, os depoimentos de terceiros, levam à conclusão de que a tese da defesa não pode ser acolhida.

A versão apresentada pelo réu, além de pueril e inverossímil, restou desmentida pelos demais elementos de prova. Trata-se de história incrível e isolada no contexto fático dos autos.

A meu ver, não é possível dar credibilidade à versão do acusado. O contexto em que os fatos se deram não corrobora, em hipótese alguma, tal versão.

Qual o motivo que as testemunhas teriam para prejudicar o réu? Pensar o contrário seria a conclusão de que as testemunhas cometeriam falso testemunho, abuso de autoridade e etc. Nada nos autos aponta que as testemunhas quisessem impor ao acusado, de forma indevida, a responsabilidade pelo delito.

A história do acusado não possui nenhum embasamento nas provas dos autos. Ora, não se nega que a responsabilidade penal é de natureza subjetiva, porém nada impede a conclusão de que o acusado tem que provar a sua versão.

Portanto, a irresignação do réu é isolada e não foi corroborada por nenhum elemento de prova nos autos, devendo ser rejeitada.

Logo, a condenação do réu pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor, em virtude das provas colhidas nos autos.

Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena.

Observando-se os elementos norteadores contidos nos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06, fixa-se a pena básica em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Ainda, aplico a pena de multa básica de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia avaliado em um trigésimo do valor do salário mínimo.

A pena foi aumentada em 1/3 (um terço), sendo que as circunstâncias não são favoráveis ao réu.

Para a aplicação da pena-base (juízo de mérito), deve-se motivar (regra de procedimento) todas as 8 circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo, consequências do crime, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, de acordo com o artigo supracitado.

O quantum de pena-base (juízo de mérito) está embasado no conjunto das oito circunstâncias judiciais, as quais têm pesos equivalentes na dosimetria, desde que sejam desfavoráveis.

Aliás, destaque-se, porque oportuno, que não há compensação ou preponderância entre as circunstâncias desfavoráveis e as favoráveis.

Por exemplo: a circunstância desfavorável dos antecedentes criminais não se compensa com a circunstância favorável da conduta social. No entanto, podem ser compensados os elementos positivos e negativos dentro da própria circunstância judicial.

Por exemplo: na conduta social podem existir elementos desfavoráveis e favoráveis. Assim, havendo preponderância dos favoráveis, a circunstância deve ser favorável ao agente e vice-versa.

Portanto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis são os motivos concretos utilizados sempre para a elevação da pena, partindo-se, como regra, inicialmente, do mínimo até o máximo, de acordo com a sanção prevista no tipo penal incriminador.

No delito de tráfico deve ser considerado, inclusive, a natureza e a quantidade da droga.

A culpabilidade deve ser dimensionada pelo grau de intensidade da reprovação penal, expondo sempre os fundamentos (dados concretos) que lhe formaram o convencimento. Nesse sentido, é fácil perceber que a circunstância é desfavorável ao acusado, pois tinha os dois requisitos doutrinários para o exame da culpabilidade: o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa.

Levou-se a cabo a avaliação tendo em conta o conjunto dos elementos subjetivos, que atuaram para a deflagração do delito em análise (os motivos; os fins e as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade).

Prosseguindo, as consequências do crime, também, foram gravíssimas.

O dano causado pela infração penal pode ser tanto material como moral. Nesse sentido, percebe-se que a conduta do réu insere-se em ambos. É material porque causa diminuição no patrimônio das vítimas, sendo suscetível de avaliação econômica. Por outra banda, o dano moral implicou dor, abrangendo tanto os sofrimentos físicos, quanto os morais para a população, que se vê aterrorizada com a onda de crimes contra a saúde pública cometidos na pacata Cidade de Mogi das Cruzes. O mal da dependência química é infligido para os familiares da vítima, possuindo reflexos perversos em grandes dimensões.

A personalidade do agente, característica correlata à motivação do crime, da mesma forma, é ponto que faz elevar a penalidade básica. A forma em que se deu o evento deixa patente a ausência de qualquer freio moral.

O réu foi detido pela posse de maconha e de crack. A quantidade e diversidade das drogas apontam que a conduta do réu atingia um número considerável de pessoas.

A respeito da natureza do entorpecente apreendido (Crack) e do seu potencial deletério em relação à saúde dos usuários e, por conseguinte, da própria sociedade, é oportuno consignar o extrato do acórdão a seguir transcrito:

“(...) Registra-se que patente a nocividade da droga apreendida, com alta capacidade de provocar dependência, conduzindo os que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade. Vale trazer à colação excertos do relatório idealizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz FIOCRUZ, em que delineados o perfil da população usuária de 'crack' e outras formas similares de cocaína fumada (pasta base, merla e “oxi”): “(.) Mais da metade dos usuários no Brasil tem padrão de consumo diário crack/similares, embora o consumo por dia tenha frequência bastante variável. O número médio de pedras usadas por usuário nas capitais é de 16 por dia (IC95%:13,0-20,5). Já nos demais municípios, o número é de 1 pedras ao dia (IC95%:9,5-13,2). A frequência elevada, especialmente nas capitais, onde também se concentram cenas de maior porte com, exemplo, 20 usuários, demonstra que a operação de uma cena de grande porte se traduz numa circulação e consumo de 3.20 pedras/dia, ou mesmo, 3.20 pedras/turno, considerando que a circulação de usuários se renova por turnos. Um mercado dessa magnitude exige a circulação intensa de redes dinâmicas de comércio local da droga e uma (ou mais de uma) interface com o mercado atacadista de pasta base, considerando que a fabricação do crack é artesanal e não se dá em grandes laboratórios, como no caso da cocaína em pó, por parte de estruturas criminais cartelizadas, segundo relatórios do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC) e agências similares. Esses dados reforçam a importância da continuidade da repressão ao tráfico de drogas nas fronteiras e também o controle dos precursores(...)”. (TJSP, 4ª Câmara Criminal Extraordinária - Apelação 0003506-85.2012.8.26.0091 - Relator Des. MAURICIO VALALA. Data do julgamento 31/07/2014)

Assim, diante de tais ponderações, cujas razões também adoto de forma suplementar, torna-se inafastável a conclusão de que a droga em questão (crack) possui alto poder de lesividade tanto à saúde do indivíduo quanto da própria sociedade, reclamando, a toda evidência, uma resposta estatal à altura.

Em resumo, o caso vertente não demonstra um “simples” caso de tráfico. As circunstâncias objetivas e subjetivas do crime fogem a normalidade, gerando repugnância ímpar. Em síntese, a fixação da pena base é plenamente justificada.

Em relação à segunda fase, a reprimenda deve permanecer no patamar fixado.

Outrossim, quanto à terceira fase, o réu não faz jus à redução preconizada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois a instrução comprovou que o tráfico era o meio de vida e que acontecia já há algum tempo. Ou seja, é perceptível que o réu dedicava-se, exclusivamente, à prática do delito de tráfico, impedindo-se a consideração da causa de diminuição. Aliás, considerá-la implicaria vilipêndio à essência da benesse, que atinge somente os chamados “pequenos traficantes”, figura que não se amolda à hipótese dos autos. Sem, contudo, deixar de lado o fato de que as circunstâncias do art. 42 e 43 da Lei nº 11.343/06 são desfavoráveis a ele.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, como determina o artigo 2º, inciso I, da Lei 8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464, de 28 de março de 2007. Ademais, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e artigos 42 e 43 da Lei de Drogas são desfavoráveis a ele.

Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, determino a incineração da droga apreendida, preservando-se 2,0g para contraprova.

Determino, ainda, a perda dos objetos encontrados, vez que utilizados para a prática do delito, implicando a perda dos objetos e do numerário encontrados.

No que tange à Lei nº 12.736/12, entendo que não deve ser considerada, pois vejamos. Trata-se de alteração que consignou modificações quanto ao instituto da detração penal, em especial da redação do seu art. 1º e 2º, causando mudanças no art. 837, § 2º, do CPP.

As mudanças da referida Lei são incompatíveis com a Constituição Federal, ceifando os princípios consagrados da individualização da pena e da isonomia.

O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, prevendo que caberá à lei regular a individualização da pena. Sabe-se que o princípio abrange três etapas, são elas: a legislativa, a judicial e a executória.

Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal. Na segunda, caberá ao juiz, à vista do delito e do contexto fático, esculpir a pena que será aplicada dentre as cominadas no tipo penal, dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, sem desconconsideração de causas que possam aumentar ou diminuir a pena. Deve, ainda, analisar qual o regime mais adequado a título de regime de cumprimento da pena, bem como a concessão de penas alternativas.

Cuida-se de critério em que o julgador possui discricionariedade regrada. Isso porque, embora tenha liberdade de escolha quanto à pena que irá aplicar, bem como sua quantidade, deve obediência a regras previstas no Código Penal e de Processo Penal.

Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei das Execuções Penais.

Com a inovação legislativa, há uma simbiose entre as etapas judiciária e de execução da reprimenda, vez que exige que o Magistrado que impõe a pena veja, ao mesmo tempo, o regime de cumprimento, mas não como início, mas sim envolvendo a perquirição sobre possível progressão de regime.

Ora, é inegável que a Lei de Execução Penal, quanto à progressão de regime, estipula a verificação de requisitos para a transferência de regime, havendo requisitos de natureza objetiva como também, principalmente, de ordem subjetiva.

Desta forma, a Lei exige que o Magistrado conceda a progressão de regime sem atentar para a análise do mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe:

A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Nesse diapasão, esqueceu-se o legislador que é imprescindível a análise do requisito subjetivo para a sua consideração. Não é crível entender que a alteração tenha o condão de excluir a demonstração, para a progressão, de que o indivíduo apresenta boa conduta carcerária, submetendo-se ao trabalho para o desconto da pena de forma digna, inexistindo, inclusive, notícia de cometimento de falta que o desabone.

Vale menção, ainda, que o exame criminológico não foi extirpado por completo do sistema da execução penal, sendo admitido. Assim:

HABEAS CORPUS - Realização de exame criminológico para concessão dos benefícios de progressão de regime e Livramento Condicional - Alegação de constrangimento ilegal afastada - Decisão fundamentada - Enunciado nº 439 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 1. A despeito de ter sido excluída a obrigatoriedade da realização do exame criminológico pela nova redação do artigo 112 da LEP, dada pela Lei nº 10.792/2003, sua determinação foi realizada com fundamentação adequada, diante das peculiaridades do caso em análise (divulgação de pornografia infantil em continuidade delitiva), razão pela qual não se vislumbra constrangimento ilegal no indeferimento dos benefícios a que afirma ter direito o paciente até a realização daquele laudo. 2. "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada" (Súmula nº 439 do STJ). 3. Ordem denegada. (TJDF - Rec nº 2012.00.2.013.214-6 - Ac. nº 603.877 - 3ª T. Crim. - Rel. Des. João Batista - DJDFTE 20.07.2012).

HABEAS CORPUS - Execução de pena - Alegação de constrangimento ilegal - Progressão - Exame criminológico desfavorável - Incidência da Súmula nº 439/STJ - Requisito subjetivo - Inexistência - Precedentes. 1. Em consenso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o exame criminológico constitui um instrumento útil para a formação da convicção do magistrado, servindo como balizamento acerca dos riscos de colocar um condenado em contato amplo com a sociedade, não se podendo reconhecer como constrangimento ilegal, pois é uma avaliação feita por meio de entrevista, sem qualquer ofensa física ou moral (Súmula nº 439/STJ). 2. A decisão motivada, consubstanciada em laudo pericial desfavorável, ao não reconhecer o preenchimento do requisito subjetivo para obtenção da benesse executória penal, encontra-se em conformidade com o artigo 112 da Lei nº 7.210/84. 3. Ordem denegada. (STJ - HC nº 232.792 - Proc. 2012/0024293-4 - SP - 5ª T. - Rel. Min. Adilson Vieira Macabu - J. 15.05.2012 - DJE 21.06.2012)

AGRAVO REGIMENTAL - Habeas corpus - Execução penal - Progressão de regime ao semiaberto deferida pelo juiz da execução - Decisão cassada pelo tribunal de origem - Necessidade de realização de exame criminológico - Ausência de fundamentação idônea. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 10.792/2003, não há mais a exigência de submissão do condenado ao exame criminológico, podendo o Juiz ou mesmo o Tribunal de origem determinar sua realização, diante das peculiaridades do caso concreto e de forma fundamentada. 2. O Juiz da execução encontra-se mais próximo à realidade do caso concreto, podendo com muito mais propriedade distinguir as situações em que se mostra desnecessária a realização do exame (HC nº 196.913/SP, Ministra Maria Thereza, Sexta Turma, DJE 30/5/2011). 3. O Tribunal de Justiça cassou a decisão do Juízo da execução - que concedeu ao paciente a progressão de regime ao semiaberto, sem a necessidade de submetê-lo ao exame criminológico, por entender preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo - tão somente devido à gravidade do delito praticado, à longa pena a ser cumprida, e à circunstância de registrar o paciente, durante a execução da pena, mau

antecedentes carcerários (prática de faltas graves, sendo a última em 2009), sem, no entanto, trazer nenhuma circunstância concreta a demonstrar a imprescindibilidade da realização da avaliação criminológica do paciente. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg-HC nº 174.582 - Proc. nº 2010/0098066-7 - RS - 6ª T. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - J. 29.05.2012 - DJE 11.06.2012).

Como se vê, o C. STJ admite o exame criminológico diante das peculiaridades do caso, sendo o entendimento sumulado (nº 439).

Pode até ser discutível o exame, mas é evidente que a progressão para o regime aberto, por exemplo, exige a realização de exames, conforme previsto no art. 114, II, da LEP. Assim:

Art. 114 - Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que: I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente; II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime.

A jurisprudência acolhe o previsto na Lei, não excluindo a necessidade dos exames:

PROCESSUAL PENAL - Agravo em execução penal - Crime hediondo - Regime prisional - Progressão - Impossibilidade - Requisito subjetivo - Descumprimento. 1 - A concessão do benefício da Progressão de Regime Prisional exige o cumprimento não só dos requisitos objetivos como também dos subjetivos; 2 - No presente caso, sendo o agravante estrangeiro, a progressão do regime está condicionada, além das disposições do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, ao preconizado pelo artigo 114, inciso I, do mesmo diploma legal; 3 - Negado provimento ao agravo. Unânime. (TJAC - Autos nº 2006.002.680-6 - Relator Feliciano Vasconcelos - J. 10.05.2007).

A Lei nº 12.736/12 voltou-se apenas para o aspecto quantitativo, deixando de lado o aspecto qualitativo. Não há direito adquirido à progressão com o simples cumprimento de parte da pena.

Outrossim, como já dito, a etapa judiciária envolve a fixação do regime mais adequado, de acordo com as condições judiciais do contexto fático. O patamar quantitativo consubstancia-se em mero indicador, não predominando sobre os critérios subjetivos para a fixação do regime.

Ademais, a Lei das Execuções Penais, que é especial, possui normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deve cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito, como colacionado acima.

Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário (Súmula nº 439 do STJ), está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A alteração não pode se prevalecer em detrimento da legislação especial, Lei de Execuções Penais, devendo esta ser observada, ainda mais quanto aos requisitos já exaustivamente discutidos acima, sendo que a análise tem de ser concretizada pelo Juízo das Execuções e não aquele que analisou o fato e impôs a pena.

Em suma, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

Finalizando, deve-se ter em mente que toda a progressão sempre pressupõe algum risco e se o condenado cometer alguma falta, merecerá a sanção devida. Caso contrário, far-se-ia letra morta das disposições legais da Lei de Execução Penal acerca da progressão de regime prisional. Nesse sentido é a jurisprudência dominante:



A evolução para quaisquer dos regimes mais brandos, como é intuitivo, sempre se reveste de acentuada carga de risco consciente, sendo certo que o absoluto, indiscutível e definitivo merecimento dela só o tempo há de indicar (RT 553/282).

Logo, deixo de considerar o previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Em razão do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu CRISTIAN DA SILVA MORAES OLIVEIRA e o CONDENADO, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo cada dia avaliado em um trigésimo do valor do salário mínimo, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no regime inicial fechado.

O acusado está recluso por causa deste processo e os motivos constatados no caso são concludentes quanto à necessidade da manutenção da decretação de prisão, razões pelas quais não poderá recorrer em liberdade.

Assim, recomende-se-o na prisão.

O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09.

Decreto a perda do numerário apreendido e dos objetos encontrados, pois instrumentos e proveito do crime.

Oficie-se à autoridade policial para que se proceda à incineração do entorpecente apreendido, consoante determina o artigo 58, § 1º, da Lei nº 11.343/06, preservando 2,0g para eventual contraprova.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e archive-se o processo.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Guararema, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA